

1501366-15.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO SOARES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de OSVALDO SOARES JUNIOR, já qualificado nos autos, como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501366-15.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501366-15.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO SOARES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,

ofereceu denúncia em face de OSVALDO SOARES JUNIOR, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Segundo consta da denúncia, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 00h41min, na Avenida Boa Vista, n. 10, Rua Isadora Correa, centro da cidade de Avanhandava-SP, o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para a entrega ao consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de maconha, totalizando 29,85g. O acusado foi preso em flagrante (fls. 01), tendo sido concedida liberdade provisória (fls. 52/53). A denúncia foi recebida no dia 15 de setembro de 2021 (fls. 73/74). Devidamente citado (fls. 109), o réu apresentou defesa prévia através de advogado nomeado postergando as teses defensivas para alegações finais (fls. 113/114). Na instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas. O réu não foi interrogado, porque teve a revelia decretada em audiência. Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Já a defesa pugnou pela absolvição. Subsidiariamente pleiteou o reconhecimento da menoridade relativa, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do crime é positiva, tal como se extrai do auto de prisão em flagrante de fls. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, bem como do laudo de constatação provisória de drogas de fls. 08/10 e também do exame toxicológico definitivos de droga de fls. 147/149, os quais identificaram vinte e nove porções de maconha pesando 29,58 gramas. A autoria do crime também é certa e restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo BO de fls. 02/04, bem como pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, como também em juízo. Na fase administrativa a testemunha PM Rodrigo Gabriel Heradão disse que "Na presente data (06/08/2021), por volta das 00:41 horas, estava realizando patrulhamento de rotina pela Rua Boa Vista, quando no cruzamento com a Rua Izidoro Correa Leite, avistamos OSVALDO SOARES JUNIOR, conhecido nos meios policiais pelo tráfico de maconha, juntamente de outro rapaz, posteriormente identificado como sendo o adolescente PEDRO SANTANA TRIVELONE, que ao notarem a presença da viatura, se assustaram e saíram andando, quando resolvemos abordá-los. Fiquei na segurança e o SD PM WESLEY iniciou as buscas em ambos. Com PEDRO, no bolso da calça esquerda de sua calça jeans, foi localizada uma porção de maconha embalada em plástico filme. Indagado a respeito, PEDRO declarou que havia acabado de comprar a porção de maconha de OSVALDO pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) e que pagaria posteriormente. Com OSVALDO, no bolso direito da blusa, o SD PM WESLEY encontrou R\$ 90,00 (noventa reais) em notas diversas e um telefone celular. Indagado a respeito, OSVALDO declarou que ganhou o dinheiro de seu avô, pois não trabalha. Já no bolso esquerdo da blusa de OSVALDO, o SD PM WESLEY encontrou 28 (vinte e oito) porções de maconha embaladas em plástico filme, idênticas a encontrada com PEDRO. OSVALDO alegou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Foi dada voz de prisão em flagrante delito a OSVALDO e de apreensão a PEDRO, sendo ambos conduzidos ao Pronto Socorro e depois apresentados nesta Delegacia. Diante do receio de fuga foi necessária a utilização de algemas em OSVALDO. PEDRO não foi algemado" (fls. 11). No mesmo sentido o depoimento da testemunha PM Wesley Dias de Almeida (fls. 12). A testemunha Pedro Santana Trivelone disse que "peguei fiado uma porção de maconha com OSVALDO e pagaria R\$ 10,00 (dez reais) por ela, quando fomos abordados pelos Policiais, que encontraram comigo somente a porção de maconha. Não sei dizer se os Policiais encontraram algo com OSVALDO. Sou usuário de maconha. É a primeira vez que compro maconha de OSVALDO" (fls. 13). Em juízo a testemunha PM Wesley Dias de Almeida disse que estavam em patrulhamento pela Rua Boa Vista quando com o cruzamento com Rua Isidoro Correa Leite avistaram duas pessoas debaixo de uma árvore, sendo que uma delas era a pessoa de Osvaldo,

que já tem bastante denúncias de que ele pratica o tráfico de drogas em Avanhanda. Quando eles viram a viatura se assustaram e começaram a andar. A equipe realizou a abordagem. O depoente realizou a busca pessoal em ambos. Com Pedro encontraram uma porção de maconha, embalada com papel transparente, plástico filme. Com Osvaldo encontraram 90 reais e vinte e oito porções de maconha, embaladas de forma idêntica à que foi encontrada com Pedro. Pedro disse que havia adquirido a porção de Pedro. Osvaldo disse que as drogas eram para consumo próprio. A testemunha PM Rodrigo Gabriel Heradão disse que estava em patrulhamento. Debaixo de uma árvore encontraram Osvaldo, que já é conhecido dos meios e mais um jovem. Ao perceberem a viatura eles saíram andando rápido. No bolso da calça do adolescente ele disse que tinha acabado de comprar a maconha de Osvaldo, que seria fiado. Na blusa de Osvaldo encontraram celular e noventa reais de notas diversas. O réu disse que o avô que tinha dado dinheiro para ele, porque ele não trabalha. No outro bolso encontrar 28 porções de maconhas, embaladas de forma idêntica da que estava com Pedro. Não se recorda se já participou de ocorrência envolvendo o réu. O réu falou que as porções eram para o uso dele.

Na fase administrativa o réu permaneceu em silêncio (fls. 14). Em juízo não foi ouvido porque preferiu a revelia.

Pois bem.

O réu foi surpreendido em via pública, na madrugada, com diversas porções de maconha (vinte e oito), embaladas em porções de aproximadamente 1g cada. A quantidade relevante de porções sendo transportadas em via pública já evidencia a destinação ao tráfico de drogas, já que um usuário não andaria com tantas porções de droga em via pública.

Não bastasse isso, a testemunha Pedro Santana Trivelone, à época adolescente, que foi encontrado com uma porção de maconha, confirmou que na data em questão havia comprado uma porção de droga do réu, fiado, o que confirma a traficância.

Em suma, diante das provas mencionadas acima, considerando ainda que o réu foi preso com dinheiro trocado, está comprovado que o acusado estava no local comercializando as drogas que levava.

Logo, o caso é de condenação do réu pela prática do tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo" e "vender".

Aplicável ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, posto que está comprovado que o acusado vendeu droga a um adolescente, razão pela qual de rigor o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

Por outro lado, verifico que o réu é primário, não possuindo maus antecedentes. Também não há comprovação de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sendo assim, de rigor a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, no máximo legal.

Passo à dosimetria da pena.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/10 (um décimo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/10 (um décimo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas por força do art. 59 do CP, mais duas previstas no art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da droga).

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no

âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena, até a fim de prestigiar a preponderância da natureza e da quantidade de drogas em relação às demais circunstâncias, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais.

O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas prevê pena de reclusão de 05 a 15 anos e de 500 a 1500 dias-multa.

Em relação à quantidade e natureza da droga apreendida nada a valorar. A culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é normal à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. No que pertine às consequências, certo é que não restaram caracterizadas outras consequências além daquelas próprias do tipo penal.

Finalmente, não há que se valorar o comportamento da vítima, pois se trata de crime vago, em que a vítima é a sociedade como um todo.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausente qualquer agravante. Presente a atenuante da menoridade relativa, que deixo de valorar, posto que a pena-base já foi fixada no mínimo legal (súmula 231, STJ). Presente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tal como já fundamentado acima, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, o dia-multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, que previa necessariamente o regime inicial fechado para os crimes hediondos.

Ademais, no HC 118.533, recentemente o STF firmou o entendimento de que o tráfico "privilegiado" do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é crime hediondo.

Sendo assim, nos termos do art. 33, §3º e 59, ambos do CP, tendo em vista a pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO (ART. 33, do CP).

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, nos termos a serem definidos pelo juiz da execução.

O réu poderá recorrer em liberdade, já que ausentes as hipóteses de segregação cautelar.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim CONDENAR o réu OSVALDO SOARES JUNIOR, pela prática do delito de tráfico "privilegiado" de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI c/c art. 33, §4º, ambos da Lei de Drogas), e, por

consequência, às penas 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Disposições finais:

a) Determino a incineração da droga apreendida, caso tal medida ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial;

b) Decreto o perdimento do dinheiro em favor da União, nos termos dos arts. 63, §1º, e 64 e da Lei de Drogas;

c) Determino a devolução do celular, posto que não houve comprovação de que o utilizava com o intuito de traficância.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, diante da situação financeira apresentada, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Intime-se o réu da sentença por edital, com prazo de 90 dias (art. 392, §1º do CPP).

Expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a multa, intimando-se para pagamento; c)

Expeça-se guia de recolhimento definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Penápolis, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA